

0000796-87.2018.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... que a ratio decidendi seja voltada ao crime de tráfico de drogas, nesse sentido decisão do C. STJ sobre o encontro fortuito que se aplica ao presente caso:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000796-87.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000796-87.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vando da Silva Almeida

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual VANDO DA SILVA ALMEIDA, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 152/154) que, entre os dias 12 de setembro de 2017 e 13 de abril de 2018, na Rua Patrick Dimitruk, nº 201, Helena Maria, nesta cidade e Comarca de Osasco, VANDO DA SILVA ALMEIDA, qualificado a fls. 06, recebeu e adquiriu, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, IMEI 359088050026709, a ser oportunamente avaliado, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, entre os dias 12 de julho de 2017 e 13 de abril de 2018, na Rua Patrick Dimitruk, nº 201, Helena Maria, nesta cidade e Comarca de Osasco, VANDO DA SILVA ALMEIDA, qualificado a fls. 06, recebeu e adquiriu, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca Lenovo, IMEI 358214077027295, avaliado em R\$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), coisa que sabia ser produto de crime.

Narra ainda a inicial acusatória que, segundo se apurou, o aparelho celular de IMEI 359088050026709, de propriedade da vítima Edson Bezerra do Nascimento, fora roubado no dia 12 de setembro de 2017, consoante boletim de ocorrência eletrônico nº 1241166/2017 (fls.32/33).

Já o aparelho de IMEI 358214077027295, de propriedade da vítima Talita dos Santos Barbosa, fora roubado no dia 12 de julho de 2017, conforme boletim de ocorrência 3644/2017, do 01º DP de Taboão da Serra.

Em data incerta, o denunciado adquiriu e recebeu, de pessoas não identificadas, e em circunstâncias não esclarecidas, ambos os celulares, mantendo-os em sua posse, sabendo de sua origem ilícita.

Na data dos fatos, policiais civis diligenciaram à residência do denunciado para cumprir um mandado de prisão temporária contra o irmão de VANDO. Ao aportarem no local, os policiais perceberam que o denunciado tentou se desvencilhar rapidamente dos agentes da lei, o que despertou suspeita, ensejando revista pessoal em VANDO, nada sendo encontrado em seu poder. No entanto, ao procederem busca na residência do denunciado, foi encontrada uma jaqueta, dentro da qual foram localizados os celulares objeto de roubo.

As vítimas de ambos os roubos não reconheceram o denunciado como autor das respectivas práticas delituosas (fls. 57/58 e 77).

Tendo em vista a total ausência de documentos que comprovassem a licitude dos bens, é evidente que o denunciado sabia da origem espúria dos celulares que estavam em seu poder.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01/04.

Auto de exibição e apreensão às fls. 14/15.

Auto de reconhecimento fotográfico negativo às fls. 54.

Laudo Pericial às fls. 79/81.

Em sede de audiência de custódia (fls. 137), foi concedido o benefício da liberdade provisória ao acusado (fls. 137/140), mediante cumprimento de medida cautelar fixada. Alvará de soltura cumprido às fls. 141/144.

A denúncia foi recebida às fls. 155, no dia 27 de novembro de 2018.

Folha de antecedentes às fls. 157/163 e 182/188.

Citado (fls. 168), o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 172).

Auto de avaliação às fls. 174/176.

O recebimento da denúncia foi ratificado às fls. 178.

Às fls. 193/197, o Ministério Público se negou a oferecer proposta de acordo de não persecução penal ao acusado. O órgão revisor manteve a negativa às fls. 223/230.

Assim, às fls. 231, foi designada audiência virtual de instrução, debates e julgamento para o dia 19.10.2022, às 14h30.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas. Ao final, foi decretada a revelia.

Em debates a Acusação pediu a condenação nos termos da inicial.

Em debates, a Defesa apontou divergências entre os depoimentos dos policiais na fase policial e em juízo. Na delegacia afirmaram que a abordagem teria sido na rua, devido ao nervosismo. Em audiência, os policiais disseram que a abordagem foi na casa, quando foram a procura de Wagner, e Vando teria autorizado a entrada no imóvel. A defesa alega que o réu estava na rua e não na casa. Os policiais afirmaram que a casa estava em aparente abandono e em busca pela casa teriam encontrado os aparelhos. Afirmou não ser crível que o réu, sendo usuário de crack, manteria dois celulares que seriam suscetível de trocar por crack. Sustentou a ilegalidade da atuação policial diante da ausência de justa causa e fundada razão para vistoria no imóvel.

É relatório.

Fundamento e decido

O pedido é improcedente.

Com efeito, a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve a superação do postulado da presunção de inocência. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito as regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas. Não é possível, dentro de um processo penal de índole democrática, a valoração da prova ser dissociada da ideia de legalidade. A legalidade da prova é um pressuposto do juízo de mérito. O processo não é um fim em si mesmo e a verdade não pode ser buscada a qualquer custo, ainda mais havendo sacrifício de direito individual. Antes de qualquer valoração racional é sempre necessário o escrutínio da fonte da prova.

Nesse sentido: “assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147).

O Código de Processo Penal, saliente-se, adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente. Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos colhidos ao arrepio de direitos individuais. O material probatório levado à análise judicial deve se revestir de legalidade, o que não se verifica no presente caso.

A sentença, portanto, é fundamentada em dois argumentos e ambos convergem para a absolvição: a) o primeiro é que toda prova é ilícita pois deriva de violação de direito constitucional – ingresso em domicílio sem justa causa prévia, fora, portanto, das hipóteses constitucionais; b) o segundo é que, mesmo que superado o argumento anterior, a versão dos policiais é totalmente dissonante e sem elemento externo de corroboração. Os relatos dos policiais, tanto em juízo, reciprocamente incoerente, quanto na fase policial, se comparados com os relatos em juízo, são divergentes e não permitem a imputação de autoria para além de qualquer dúvida.

A dinâmica fática relatada em juízo pelos policiais, em resumo, consiste no fato de que foram ao endereço para cumprir mandado de prisão temporária do irmão do réu (Wagner). O réu, o qual estava no local, teria franqueado a entrada na residência e, após resolverem pela revista no local, encontraram – na verdade o policial José teria encontrado – dois celulares que estavam dentro de uma Jaqueta. Diante deste fato – não sabendo informar se consultaram ou não o IMEI no momento – levaram o réu para a delegacia de polícia.

Pois bem. De início, cumpre salientar que, seja a abordagem derivada de nervosismo – como os policiais alegam na fase policial – e posterior ingresso no domicílio, seja o ingresso no domicílio para cumprir mandado de prisão temporária, em ambos, a ilegalidade é manifesta.

Com efeito, em se considerando a abordagem na rua e posterior entrada no domicílio, tal procedimento é eivado de nulidade eis que, em primeiro lugar, nada de ilícito foi encontrado com o réu quando da abordagem, caso se aceite que tenha ela sido realizada na rua por conta do nervosismo. Em segundo lugar, não é possível que se aceite que o réu tenha autorizado o ingresso eis que, no momento, estava com a vontade coarctada diante da abordagem policial.

Por outro lado, caso se desconsidere a abordagem na rua e se assuma que esta fora na residência quando os policiais foram cumprir mandado de prisão temporária, além de não se aceitar a autorização para ingresso, como acima aludido, o objeto do cumprimento da ordem judicial era prender o irmão do réu e não realizar busca e apreensão no imóvel.

Assim, no caso dos autos, percebe-se que a localização dos celulares após ingresso na residência derivou de sorte. Não havia justa causa prévia que justificasse a busca domiciliar eis que, repita-se, o objeto do mandado era a prisão do irmão do réu.

Os policiais, nesta segunda hipótese, conforme afirmaram em juízo, foram à casa do réu (ou de seu irmão) com vistas a prenderem Wagner. Não estando Wagner no local, ingressaram no imóvel e, segundo afirmam, localizaram os celulares, os quais, inicialmente, sequer sabiam ser produto de crime. Não há, portanto, relação entre este argumento (diligências para localização de pessoa procurada) e o ingresso na residência e posterior apreensão de celulares. Há, portanto, claro desvio de finalidade na conduta dos policiais até porque não havia qualquer informação acerca de objetos ilícitos no local. O encontro dos celulares (dentro de uma jaqueta) se deu de modo fortuito eis que não estava no espectro de alcance da atividade policial a apreensão de qualquer objeto de natureza ilícita. Tratou-se, na verdade, de verdadeira investigação especulatória ou fishing expedition.

Mesmo que a ratio decidendi seja voltada ao crime de tráfico de drogas, nesse sentido decisão do C. STJ sobre o encontro fortuito que se aplica ao presente caso:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DESVIO DE FINALIDADE E FISHING EXPEDITION. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o

ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

3. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

4. Sobre a gravação audiovisual, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas"), reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos".

5. Por se tratar de medida invasiva e que restringe sobremaneira o direito fundamental à intimidade, o ingresso em morada alheia deve se circunscrever apenas ao estritamente necessário para cumprir a finalidade da diligência, conforme se extrai da exegese do art. 248 do CPP, segundo o qual, "Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência".

6. É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas.

7. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

8. Segundo Alexandre Morais da Rosa, "Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder

para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser físgados, muito menos a quantidade" (ROSA, Alexandre Moraes da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390).

9. Sobre o desvio de finalidade no Direito Administrativo, Celso Antonio Bandeira de Mello ensina: "Em rigor, o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio da legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; está nele contido, pois corresponde à aplicação da lei tal qual é; ou seja, na conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista do qual foi editada. Por isso se pode dizer que tomar uma lei como suporte para a prática de ato desconforme com sua finalidade não é aplicar a lei; é desvirtuá-la; é burlar a lei sob pretexto de cumpri-la. Daí por que os atos incursos neste vício – denominado 'desvio de poder' ou 'desvio de finalidade' – são nulos. Quem desatende ao fim legal desatende à própria lei" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, 27 ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 106).

(...)

(STJ – 6ª Turma – HABEAS CORPUS Nº 663055 - MT (2021/0128850-8) - Ministro Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Brasília (DF), j. 22 de março de 2022.)

Assim, por todos os lados que se analisa a questão, não havia fundadas razões para o ingresso domiciliar sem autorização judicial eis que não havia situação de flagrante ou suspeita de flagrante, além do que a autorização do proprietário não pode ser considerada válida devido a coação sistêmica e contextual.

Por outro lado, ainda que se supere o escrutínio de legalidade, as provas não demonstram, com a segurança, para além da dúvida razoável, a premissa fático-acusatória de que o acusado (i) entre os dias 12 de setembro de 2017 e 13 de abril de 2018, na Rua Patrick Dimitruk, nº 201, Helena Maria, nesta cidade e Comarca de Osasco, recebeu e adquiriu, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, IMEI 359088050026709, a ser oportunamente avaliado, coisa que sabia ser produto de crime; (ii) entre os dias 12 de julho de 2017 e 13 de abril de 2018, na Rua Patrick Dimitruk, nº 201, Helena Maria, nesta cidade e Comarca de Osasco, VANDO DA SILVA ALMEIDA, qualificado a fls. 06, recebeu e adquiriu, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca Lenovo, IMEI 358214077027295, avaliado em R\$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), coisa que sabia ser produto de crime.

Quanto a estas premissas, de rigor salientar que as provas produzidas em juízo, ainda mais se comparadas com o que fora dito na fase policial, não são suficientes para a atribuição de responsabilidade penal ao réu, tendo em vista dúvidas quanto a própria autoria.

Os policiais, mesmo não tendo afirmado tal fato na delegacia, em juízo relataram que a casa estaria abandonada, mas que o réu guardaria alguns pertences e que o local parecia ser destinado ao consumo de drogas de outras pessoas. Assim, com base nesta descrição, é fato que, segundo os policiais, outras pessoas frequentavam a casa. Nessa ordem de ideia, sendo o local frequentado por outras pessoas, inclusive o mandado de prisão do irmão do réu era para referido endereço, segundo as testemunhas, não é possível afirmar com certeza de que os celulares estivessem sob o espectro de domínio do réu. Em outras palavras, que os celulares lhe pertenceriam. E mais, de fato, como apontado pela defesa, sendo o réu consumidor de crack (os policiais afirmaram que tinha aparência de ser usuário de crack) não se tem como crível o fato de que o réu guardaria os celulares sem negociá-los até porque, segundo a inicial, os ilícitos patrimoniais que envolveram os celulares são datados de julho de 2017.

A única certeza dos autos é o encontro dos celulares. Entretanto, a autoria por

parte do acusado das condutas típicas afirmadas pela acusação na inicial, com base nas provas colhidas em contraditório judicial, permanece obnubilada.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria. A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido em contraditório judicial. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal e ABSOLVO VANDO DA SILVA ALMEIDA da acusação de ter infringido o artigo 180, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 368, inc. VII do Código de Processo Penal.

Tendo os celulares sido devolvidos, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Ciência ao Ministério Público.

Osasco, 19 de outubro de 2022.